

1500457-23.2021.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Roberto Sylla

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... - Unânime - J. 19.10.2017).

"Tráfico de drogas. Inexigibilidade de conduta diversa. Tráfico privilegiado.

Natureza e quantidade da droga apreendida. Fração de diminuição. 1 - O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para prover o sustento, deve ser punido, dado a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde pública - e a inexistência de norma expressa que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500457-23.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500457-23.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Roberto Sylla

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ADEMIR FRANCISCO DA SILVA, qualificado às fls. 05/06, imputando-lhe a prática do crime descrito nos artigos 33, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de maio de 2021, por volta das 23h15, na Rua Pedro Tófano, n.º 214, Jardim Marisa, e na residência localizada na Rua Kinjiro Ricci, n.º 182-B, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente/SP, ADEMIR FRANCISCO DA SILVA, qualificado às fls. 05/06, trazia consigo e mantinha em depósito 06 (seis) invólucros plásticos contendo 151,11g (cento e cinquenta e um gramas e onze centigramas) de maconha e 02 (dois) tabletes de maconha, totalizando 890,98g (oitocentos e noventa gramas e noventa e oito gramas), embalados em uma sacola plástica, para fins de fornecimento a terceiros, consoante auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13/14), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 17/18) e laudo pericial

definitivo a ser oportunamente juntado. Segundo apurado, o denunciado adquiriu de terceiro não identificado os dois tabletes de maconha acima descritos com o intuito de fracioná-los e revender a droga nesta cidade. Na data do ocorrido, trazia consigo 06 (seis) invólucros plásticos contendo maconha no bolso direito de seu agasalho, para fins de fornecimento a terceiros, quando avistou uma viatura e fugiu, correndo em direção ao portão de sua casa. Ao ser abordado pelos policiais militares, o denunciado se rendeu e lhes entregou as porções de maconha. Ato contínuo, os policiais procederam a vistoria na residência do denunciado, onde a quantia de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais) em notas de pequeno valor foi apreendida, em uma bolsinha vermelha no quarto do denunciado, proveniente da venda de droga. Dando continuidade às diligências, os policiais rumaram em direção a residência da namorada do denunciado, onde ele mantinha em depósito os dois tabletes de maconha em uma cama box abandonada na área externa. Considerando a apreensão de entorpecente já separado e embalado para a venda, bem como de grande quantidade na forma de tabletes a ser fracionado para ulterior revenda, não há dúvidas de que a substância entorpecente apreendida tinha como destino a mercancia ilícita. Requisitou-se exame pericial definitivo da substância entorpecente apreendida - fls. 70/71.". Acompanha a denúncia o respectivo inquérito policial. Após regular citação apresentado defesa preliminar (fls. 130/134), sobre a qual o Ministério Público se manifestou (fls. 138), o despacho de fls. 148/145, de 29 de julho de 2021, recebeu a denúncia e determinou a produção de provas. Em alegações finais, o nobre Dr. Promotor de Justiça (fls. 187/191), pediu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, o ilustre Dr. Defensor (fls. 198/204), requer a absolvição do réu, por inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que o réu e sua família passavam por dificuldades financeiras, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Na remota hipótese de condenação requer o reconhecimento da boa conduta social do agente, seus bons antecedentes e a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo a confissão espontânea do réu, bem como a figura do tráfico privilegiado, com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, e em regime menos gravoso para cumprimento da pena.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, verifica-se que nenhuma nulidade há, eis que o processo tramitou de forma regular, sendo respeitados todos os preceitos legais e não havendo preliminares arguidas.

Passo à análise do mérito.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

A materialidade dos fatos narrados na denúncia e imputados ao réu encontra-se suficientemente demonstrada nos autos pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12; pelas fotografias de fls. 13/16; pelo auto de constatação preliminar de fls. 17/18; pelo laudo químico toxicológico de fls. 96/98, atestando - Item A (Acondicionado sob o lacre 0035279 ) Descrição: 06 (seis) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos. Massa Bruta e/ou Quantidade: 162,71 grama(s) - cento e sessenta e dois gramas e setenta e um centigramas. Massa Líquida: 145,07 grama(s) - cento e quarenta e cinco gramas e sete centigramas. Item B (Acondicionado sob o lacre 0035280 ) Descrição: 02 (dois) invólucro(s) plástico(s) do tipo "filme" retorcido encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo. Massa Bruta e/ou Quantidade: 901,73 grama(s) - novecentos e um gramas e setenta e três centigramas. Massa Líquida: 880,64 grama(s) - oitocentos e oitenta gramas e sessenta e quatro centigramas. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em camada delgada e foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da

Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); Laudo pericial de objetos de fls. 104/106 que analisou - Item Único (Acondicionado sob o lacre 0016390 ) Descrição: 1 (uma) sacola plástica, apresentando diversas inscrições, entre elas "MALWEE", com solução de continuidade e fita adesiva aderida, apresentando resquícios/sujidades. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e , NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III, conforme a(s) técnica(s) utilizada(s) (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020); além da prova oral carregada para os autos.

Em Juízo, o PM Matheus Porto Genaro, sob o crivo do contraditório declarou que estavam em patrulhamento e avistaram o Ademir na calçada na Rua Pedro Tofano, e ao avistar a viatura, mudou repentinamente de direção e apertou o passo o que gerou as fundadas suspeitas e o abordamos na entrada de um portãozinho, que vieram a saber que era de sua residência, e em revista pessoal, localizamos no bolso da blusa que usava seis porções de substância que aparentava ser maconha. A mãe, salvo engano a irmã e o irmão de Ademir que estava dentro da residência, saiu foi-lhe informado o que estava acontecendo e autorizou imediatamente a entrada da equipe na residência. Durante a revista, no quarto do acusado localizaram uma carteira vermelha com R\$ 160,00 e indagado sobre o dinheiro, ele disse que era proveniente do tráfico de drogas e que já havia gastado uma parte desse dinheiro. Ao ser indagado ainda se haveria mais entorpecentes, disse ele que ali não tinha, mas que estavam na casa de sua namorada, então perguntaram se teria condições de levar a polícia até lá, ele concordou e o conduzimos até a casa de sua namorada onde localizamos no local indicado por ele, mais porções de maconha. Não conhecia o réu antes dos fatos. Não foi localizado nenhum apetrecho para o preparo ou embalo da droga. Está em Presidente Prudente desde a criação do 8º BAEP. Acredita que o réu tenha colaborado com o esclarecimento do crime, de livre e espontânea vontade. O depoimento dos policiais é suficiente para alicerçar a culpa do acusado, que deve provar sua inocência com os meios que obtiver.

Transcrevo decisões a respeito do crime ora tratado, relativamente à impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecente, bem como sobre a credibilidade da palavra dos policiais envolvidos com a descoberta e detenção dos envolvidos:

"PROVA - Depoimento de policial que efetuou a prisão em flagrante - Declarações harmônicas e seguras - Suporte suficiente à condenação - Inteligência dos artigos 6º, III, e 202 do CPP. PROVA - Depoimento de policial - Credibilidade dos testemunhos em geral enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. ((RT 668/275 - TJSP - rel. Des. Jarbas Mazzoni))".

Nesse ponto, nunca é demais lembrar que "como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" - "Prova criminal - Testemunha - Hipótese de Tóxico. Depoimentos prestados por policiais. Validade. Presunção 'iuris tantum' de agirem escorreitamente no exercício da função. (TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: (RT 591/313 e 654/278).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. ((STF HC 74.608-0 de São Paulo rel. Min. Celso de Mello DJU 11.04.97, pág. 12.189))"

Observe-se que o depoimento dos policiais foi uníssono, seguindo no mesmo sentido e

meros desencontros sobre circunstâncias acessórias e paralelas ao núcleo central do comportamento criminoso não são suficientes para retirar a credibilidade que merece a prova testemunhal produzida nos autos, conforme pretende a defesa.

Aliás, não há nos autos qualquer elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente a acusada, motivo pelo qual não se pode desmerecer a fala dos policiais pelo só fato de pertencerem aos quadros da Polícia Militar.

Sobre a validade do depoimento de policiais, relembro que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que “o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento” (STF RHC Rel. Min. Moreira Alves JSTF-Lex 125/332).

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu o seguinte:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivo expressos no CPP determinando que a Polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

Demais disso, tem-se que “em sede de repressão aos tóxicos, contrapondo-se à palavra do agente à do policial-condutor, prevalece o depoimento do miliciano, salvo existência de prova diversa em contrário” (TACRIM-SP AC Rel. Lauro Malheiros JUTACRIM 30/328), valendo acrescentar que “pequenas divergências em depoimentos prestados pelas testemunhas, sem ofensa à essência do que contém, não são motivos para torná-los imprestáveis” (TJRJ EI Rel. Antônio Carlos Amorim RTJE 70/278).

A testemunha Maria Amantino Dias, sob o crivo do contraditório declarou que conhece o réu há aproximadamente dez anos, sabe que ele recebe pensão pois é inválido, não trabalha. Não assistiu a prisão de Ademir, não tinha ouvido falar também que ele fazia o tráfico de drogas. Mora na mesma rua que a casa do réu, considerado vizinho. Não ficou sabendo se ele faz parte de alguma organização criminosa. Sabe que é uma pessoa boa, normal, tranquilo.

O réu Ademir Francisco da Silva, em seu interrogatório declarou que nunca foi preso ou cumpriu pena de prisão, um por porte de droga (artigo 16 da antiga Lei de Drogas). Sobre os fatos disse que são verdadeiros. Estava precisando de dinheiro, passando por dificuldades pois sua esposa faleceu. Começou a vender droga para ajuda-la, precisando de remédio e havia muita conta. Havia quinze dias que pegou a droga para vender. Pagou R\$ 1.400,00 pela droga. Fez o tráfico por necessidade. Nunca tinha feito o tráfico antes, foi a única vez, e ultima, foi somente por necessidade. Afirma que a esposa passava por necessidade, estava doente, precisando comprar remédios, e no prontuário consta que faleceu de corona virus, mas tinha muitos problemas, tomava muitos remédios caros.

O valor probante da confissão em juízo é inequívoco.

Transcrevo trechos doutrinários a respeito:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete Processo Penal ed. Atlas, 8ª edição, pág. 288).

Aliás, também o dizia Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas estantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa. (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1.999, pág. 114).

Com efeito, a quantidade de droga apreendida e pertencente ao réu (várias porções de maconha pesando 151,44 gramas (seis invólucros) e 2 tabletes pesando 890,98), bem como numerário (R\$ 160,00), embalados em uma sacola plástica, para fins de fornecimento a terceiros, além das circunstâncias que se desenvolveram os fatos, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in casu.

Não prospera a alegação de que a droga era para aplacar a necessidade financeira que estava passando, já não conseguiu comprovar quando a sua mulher faleceu e nem o real motivo, se limitando apenas a informar que ela tinha "muitos problemas" e que "tomava um monte de remédio caro", que são insuficientes para demonstrar realmente sua situação financeira desfavoráveis.

Por outro lado, a droga fora apreendida na casa de sua namorada que também estava com Covid-19, e foi internada no mesmo dia da sua prisão, aliado a tudo isso, disse que comprou a droga pelo valor de R\$ 1.400,00 havia 30 (trinta) dias, conforme consta em seu depoimento quando da lavratura da prisão em flagrante (fl. 5).

Assim, não é crível que venha a justificar a sua intenção para a prática de tráfico de drogas, por estar passando por dificuldades financeiras, haja vista que não se sabe, se a esposa ou a namorada que passava por dificuldades, quais remédios que ela necessitava, e nem a confirmação do falecimento como narrado por ele em Juízo. Dessa forma, demonstrada a sua real intenção quanto a conduta do tráfico de drogas, em que pese a argumentação da d. Defesa do réu, alegando que este passava por dificuldade e não teve outro caminho a não se enveredar pelo crime, portanto, a sorte não lhe foi favorável e acabou sendo preso pelo crime em comento, ficando demonstrado que as razões alegadas não foram sequer provadas, a dificuldade financeira, a compra de remédios caros para sua mulher, quem era a sua esposa e sua namorada atual, de tal sorte que não há como acolher o pedido de inexigibilidade de conduta diversa do réu. Até porque, disse que adquiriu a droga recentemente pelo valor de R\$ 1.400,00, difícil crer que alguém passa necessidades financeiras quando se tem em sua posse esse expressivo valor, ainda mais que sendo ele aposentado por invalidez, recebe mensalmente uma pensão, que também não trouxe aos autos, documentos comprobatórios, ficando apenas no campo do suposto.

Corroborando a tudo isso é o laudo do incidente de verificação de dependência toxicológica, o expert constatou que o paciente "é usuário eventual de maconha e não apresenta Transtorno ou Doença mental decorrente do uso de drogas. Apesar do nível intelectual rebaixado, este não prejudica sua capacidade de entendimento ou determinação. Tinha á época dos fatos plena capacidade de entendimento e determinação quanto a ação que lhe é imputada." A conclusão do exame foi que o réu: "- Não é dependente químico. - Não há doença ou Transtorno mental. - É pessoa plenamente capaz de entender e de se determinar. - Não havia prejuízo de entendimento ou determinação pelo uso de drogas."

Assim sendo, o réu tinha a plena capacidade de entender a ilicitude da conduta por ele praticada, e a liberdade para escolher qual conduta praticar, ao contrário, para afastar a responsabilidade penal do acusado por inexigibilidade de conduta diversa, este não poderia agir de outra maneira para evitar a prática do crime, que ficou evidente nos autos.

Nesse sentido, ficou claro que o réu tinha a liberdade para poder escolher entre praticar ou não um crime tão grave e tão nefasto para a sociedade em geral, crime este que corrompe uma legião de jovens e crianças a prática reiterada de outros diversos crimes para poder sustentar cada vez mais o seu vício. Sem entrar em conjecturas, poderia ele agir de outra maneira para amenizar a situação porque supostamente vinha passando.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, E §4º, C/C ARTIGO 40, INCISO III, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO. (I) ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS E TRAGÉDIA FAMILIAR QUE NÃO AFASTAM A ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA. VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NÃO ENSEJA A ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. (II) DOSIMETRIA DA PENA. (...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO."

(TJPR - 3ª C.Criminal - AC - 1660010-7 - Piraquara - Rel.: Paulo Roberto Vasconcelos - Unânime - J. 19.10.2017).

"Tráfico de drogas. Inexigibilidade de conduta diversa. Tráfico privilegiado.

Natureza e quantidade da droga apreendida. Fração de diminuição. 1 - O crime de tráfico de drogas, ainda que cometido para prover o sustento, deve ser punido, dado a relevância do bem jurídico tutelado - a saúde pública - e a inexistência de norma expressa que isente a culpabilidade neste caso. 2 - A natureza e a quantidade da

droga apreendida - a serem examinadas de forma conjunta - servem de parâmetro para a escolha da fração de diminuição do § 4º do art. 33 da L. 11.343/06. 3 - Se a ré, primária e de bons antecedentes, é presa com quantidade não significativa de drogas -- 0,70g de crack --, apesar da natureza, adequada a redução da pena, em razão do tráfico privilegiado, na fração máxima legal (2/3). 4 - Apelação provida em parte." (TJ-DF 00185675420168070000 DF 0018567-54.2016.8.07.0000, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 15/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por certo que a aventada dificuldade financeira não é motivo autorizador da prática delituosa.

Fato incontroverso é que, segundo os policiais militares, seus depoimentos demonstra com clareza a prática do crime de tráfico de drogas, pois, foi ele preso com 6 porções de maconha, que admitiu, depois foi encontrado dinheiro, R\$ 160,00 que ele mesmo admitiu que era produto tráfico e já tinha gasto uma parte desse dinheiro, bem como também confessou que tinha em depósito, guardado na residência da namorada, mais porções da mesma droga.

Os demais elementos de prova dos autos demonstram a ocorrência do delito de tráfico de drogas diante da conduta do réu, não só pela apreensão das drogas nos dias dos fatos, mas pela ocorrência dos fatos como informado através da Polícia Militar; não só da droga mas também do dinheiro que recebera da venda do entorpecente, num total de R\$ 160,00 (setecentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), o que por si só, não denotam o crime de tráfico, mas aliada as demais circunstâncias, dois tabletes de massa bruta que pesou cerca de 890,98 gramas de maconha, que renderia inúmeras porções quando fracionadas para a venda.

Por tudo isso, demonstrada, a saciedade, a atividade espúria realizada pelo réu. Outrossim, a droga apreendida, conforme se vê nas fotografias de fls. 13/16, corroborado com os depoimentos dos policiais, era suficiente para demonstração da traficância, e além do mais, o réu confessou a origem lícita do numerário apreendido em sua posse, fruto da traficância de drogas por ele exercida.

Por outro lado, desnecessário a apreensão de apetrechos para a configuração do crime, conforme questionamento pelo Defensor do réu ao Policial Militar Matheus. Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas contidos nos autos, anotando-se que a palavra da testemunha se reveste de coerência, robustez e segurança e não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceita como elemento hábil à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-la, o que não fez.

Quanto à destinação dos entorpecentes apreendidos nos autos, imperioso salientar que o elemento subjetivo do tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos não é perceptível logo de início, mas através das circunstâncias externas do caso concreto, as quais acabam por traduzir a intenção dos agentes.

Na hipótese dos autos, a droga apreendida, aliada ao modo como foram encontradas, denota sua destinação ao comércio ilegal. Importante ressaltar, inclusive, que tanto na sua posse como escondido na residência da namorada, ambas demonstram a principal destinação das drogas.

É o quanto basta para embasar a condenação.

Nesse sentido: "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Tóxico - Tráfico - Circunstâncias que induzem a caracterização do delito. A existência de denúncias anônimas, a diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, parte embalada e pronta para a venda clandestina, são circunstâncias que induzem a caracterização do tráfico." (Apelação Criminal n.º 223.036-3 - Sorocaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 01.07.97 - V.U.);

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Circunstâncias que evidenciam a condição de traficante - Recurso não provido. Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu, no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a sua prisão." (Apelação Criminal n.º 152.279-3 - Marília - 3ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 19.06.95 - V.U.).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Configuração - Materialidade e autoria demonstradas - Prova - Confissão policial de co-réu - Retratação judicial isolada - Palavra de

policiais - Validade - Quantidade e modo de acondicionamento que revelam o fim de comércio - Flagrante preparado - Inocorrência - Pena - Pretendida substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Crime hediondo Regime integralmente fechado - Manutenção - Recursos não providos." (Apelação Criminal n. 281.880-3 - Guaratinguetá - 4ª Câmara Criminal - Relator: Passos de Freitas - 08.02.00 - V.U.).

Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga à terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado.

Nesse sentido: "Não é indispensável a aprova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido" (TJSP RT 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3,3.8.94, p.8745); "Constituem elementos de convicção, que evidenciam a condição de traficante, as denúncias anônimas, a quantidade da substância apreendida, a forma de sua embalagem, a conduta do réu no momento da apreensão e as circunstâncias em que se dá a prisão" (Ap. Crim. 152.279.3, 3ª Câmara, j. 19.06.95 Rel. Des. Bittencourt Rodrigues).

Por fim, fica devidamente evidenciado que o réu, a fim de evitar transitar com grande quantidade de droga, guardava a maior quantidade na residência da namorada, de onde retirava parte para a venda a terceiro.

Diante de tudo que foi amealhada aos autos, as provas produzidas são suficientes para crer que o réu realizava efetivamente o comércio de drogas, procedendo a ação penal como pedido na denúncia.

Por fim, conclui-se, destarte, que o réu realizara conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se lhe a condenação e a pena, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

Por tudo isto é que procede a ação penal e é de rigor a condenação do réu.

Passo a dosagem da pena.

No tocante à circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, no aumento da pena base em decorrência da quantidade, da diversidade das drogas e sua natureza das mesmas; e a aplicação desses mesmos motivos, quantidade, diversidade e natureza das drogas para negar a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que não é possível por violar o princípio do bis in idem.

"Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão. (STF; HC 145362, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020).

Neste ponto, é forçoso reconhecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs n.º 112776 e n.º 109193, em 19/12/2013, decidiu que não é possível a utilização cumulativa da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer em bis in idem:

"[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. OBRIGATORIEDADE DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ART. 2º, DA LEI 8.072/1990. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o art. 42 da Lei

11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. O magistrado sentenciante considerou a natureza e a quantidade de droga simultaneamente na primeira e na terceira fase de individualização da reprimenda, em flagrante bis in idem. [...]" (HC 112776, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Também decidiu: "[...] HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA SOMENTE NA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/06, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). Essa opção permitirá ao juiz aplicar mais adequadamente o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) em cada caso concreto. 2. No caso, a natureza da droga apreendida foi utilizada somente na terceira etapa da dosimetria, ou seja, para fixar o fator de redução da causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, não havendo, portanto, violação ao princípio do ne bis in idem.[...]" (HC 109193, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Portanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada nas primeira e terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância possa ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma).

Presente a causa de diminuição em comento, entendo que a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio STF, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que tivessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena".

"PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO APRECIADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (ARE 666334/RG), a quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase, para elevação da pena-base, quanto na terceira etapa, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Todavia, devem ser consideradas apenas em uma das fases, sob pena de bis in idem. [...]" (Acórdão n.1122497, 20170110292870APR,



Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 169/173) "[...] 3. O Supremo Tribunal Federal entendeu que caracteriza bis in idem a análise da natureza e da quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, e também na terceira, para graduar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. [...]" (Acórdão n.1110966, 20160110770556APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 30/07/2018. Pág.: 97/114).

Ressalte-se que esse entendimento prevalece mesmo que os citados elementos (quantidade e natureza da droga) sejam cindidos em diferentes circunstâncias ou fases.

"[...] 1 - As circunstâncias especiais - natureza e quantidade da droga - devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser consideradas, cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem. [...]" (Acórdão n.1112143, 20170110075896APR, Relator JAIR SOARES, Revisora: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2018, Publicado no DJE: 01/08/2018. Pág.: 165/181).

"[...] 4. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a valoração da natureza e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria para subsidiar a fixação de pena-base acima do piso legal, bem como para graduar a diminuição da pena diante do privilégio estatuído no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem. Não se admite a separação dos vetores - quantidade e natureza - para esse fim. [...]" (Acórdão n.1077373, 20160110898110APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 298/324).

A jurisprudência entende que, à míngua de critérios fornecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como critério de fixação da fração de redução da pena:

"[...] 3 A redução da pena pela fração mínima prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, se justifica pela natureza e quantidade das drogas apreendidas. [...]" (Acórdão n.994019, 20130111131885APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisora: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 244/255).

"[...] 5. Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não comprovada a dedicação a atividades ou organizações criminosas, aplica-se a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da LAD, porém, pela metade, tendo em vista a quantidade e a natureza da droga. [...]" (Acórdão n.953819, 20150110790220APR, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2016, Publicado no DJE: 13/07/2016. Pág.: 99/126).

Portanto, levando-se em consideração a quantidade de drogas apreendida, entendo que a aplicação da causa especial de diminuição de pena em comento na fração de 1/2 (metade) mostra-se proporcional.

Nesse sentido:

[...] 1. Não sendo a quantidade de droga apreendida irrelevante (720,88g de massa líquida de maconha), razoável a incidência da fração de ½ (metade) de diminuição (§4º do artigo 33 da LAD). [...]" (Acórdão 1160518, 20180110068803 APR, Relator: SILVANO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: 152/174).

"[...] 5. Na hipótese de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, a quantidade da droga apreendida (588g de maconha) justifica a redução da pena no patamar de 1/2 (metade). [...]" (Acórdão 1123911, 20170110259838APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/9/2018, publicado no DJE: 17/9/2018. Pág.: 186/198).

"[...] 3 A dosimetria é irretocável quando a pena é fixada no mínimo legal nas duas primeiras fases e foi reduzida por metade na fase final, considerando a diversidade de drogas apreendidas e a sua natureza. [...]" (Acórdão 1000569, 20130110716564 APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de

juízo: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74).

Nesse cenário, deve ser mantida a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade).

Portanto, na dosagem da pena, levo em consideração que o réu é primário e não registra antecedentes, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, lhe são favoráveis, fixo a pena base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias multa cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea do réu em Juízo, conforme preceitua o artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, entretanto, deixo de reduzir a reprimenda, porquanto nessa fase do cálculo penal não pode ficar abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

Na terceira e última fase, presentes os requisitos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que é aplicável a causa de diminuição de pena nele estabelecida.

Com efeito, a par da primariedade técnica, não se evidenciou ser o acusado pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

As quantidades de drogas e de dinheiro apreendidos em poder do réu são diminutas, sendo possível crer que ele não se trata de criminoso contumaz.

Reduz-se, pois, em razão da quantidade de droga apreendida, a pena na proporção de 1/2 (metade), de modo a resultar em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos narrados na denúncia, tornando-a definitiva neste ponto, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

No caso concreto, considerando não só a primariedade e a ausência de antecedentes, mas também, a circunstância de não ser considerada a quantidade de droga e o pouco de dinheiro apreendido com o réu, entende-se viável a fixação do regime inicial aberto.

Por outro lado, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, entende-se também cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplica do

redução prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital do Câncer de Presidente Prudente.

Em caso de revogação das penas restritivas de direitos, o réu cumprirá a pena corporal fixada nesta sentença no regime aberto.

ISTO POSTO e o que mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu ADEMIR FRANCISCO DA SILVA, RG: 43367585, nascido em 28/12/1986, natural de Presidente Prudente - SP, filho de WALDEMAR FRANCISCO DA SILVA e APARECIDA DE LOURDES GOIS DA SILVA, a cumprir a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e por uma pena pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente na data do pagamento em favor do Hospital da Esperança de Presidente Prudente (Hospital do Câncer); e a pagar a multa de valor correspondente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, cada dia no valor mínimo legal, por violação do artigo 33, caput, c/c o artigo 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Quando da execução as multas deverão ser corrigidas monetariamente a partir da data dos fatos da denúncia.

Em razão do dinheiro apreendido, fruto da prática do grave crime de tráfico, decreto a sua perda em favor da União. Comunique-se.

Condeno o réu a pagar as custas processuais. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita. Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente, 24 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA